

1501344-44.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2260983/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20448477 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

8899/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2260983 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501344-44.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501344-44.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2260983/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20448477 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

8899/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2260983 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

8899/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO FELIPE CUSTÓDIO GARDINALI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

KAIO FELIPE CUSTÓDIO GARDINALI, qualificado nos autos (menor de 21 anos de idade), foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, segundo consta na denúncia, no dia 23 de setembro de 2021, por volta de 16h45min., na Rua Presidente Tancredo Neves, altura do nº 646, Bairro

Rosele, nesta cidade e comarca de Araçatuba-SP, o réu, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita, 03 (três) porções de benzoilmetilecgonina (cocaína), droga capaz de produzir dependência. A droga estava acondicionada em microtubos plásticos de cor amarela.

Consta também que em 23 de setembro de 2021, instantes depois, na “Viela Cafezinho”, no Bairro Rosele, nesta cidade, o réu, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito, para comercialização ilícita, 20 (vinte) porções de benzoilmetilecgonina (cocaína), droga capaz de produzir dependência. A droga estava acondicionada em microtubos plásticos de cor amarela.

O réu foi preso em flagrante em 23/09/2021 (fl. 05). Pela r. decisão de fls. 46/47, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Mandado de prisão cumprido em 24/09/2021 (fls. 68/69). Sobreveio r. decisão de fls. 130/136, concedendo a liberdade provisória em favor do acusado. Alvará soltura cumprido em 03/12/2021 (fls. 144/146).

Devidamente notificado (fl. 128), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 148/152. A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022, ocasião em que foi deferida a gratuidade da justiça ao acusado (fls. 164/166). Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha em comum, sendo, ao final, interrogado o réu (fls. 208/212).

Em alegações finais orais (fl. 210), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da ação penal nos moldes da denúncia, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa. Na dosimetria da pena, requereu seja considerada a circunstância atenuante da confissão espontânea, com fixação do regime inicial, no mínimo, semiaberto, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pleiteou o perdimento dos valores apreendidos nos autos em favor da União.

Em alegações finais (fls. 211/212), a Defesa pugnou, em síntese, pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3; a imposição de regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fl. 14), laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fl. 33), laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 104/106, relatório final (fls. 107/108), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

A testemunha comum Ary Rideto Kaneyasu, policial civil ouvido em juízo (fl. 209), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 08), disse que receberam uma informação de que um rapaz estaria traficando entorpecentes próximo a um bar, na Rua Tancredo Neves, sendo que foram com a viatura policial até o local, descaracterizados. O local era condizente com as informações recebidas. Relatou que no local encontraram o acusado, que estava com 03 (três) pinos de cocaína.

Realizando uma breve campana, observaram o réu entregando algo a uma pessoa não identificada em um veículo. De início, ao abordarem o acusado, ele disse que não era usuário e não vendia drogas, mas posteriormente acabou confessando a prática do delito. O acusado disse que sua esposa estava grávida e, no momento, ele estava desempregado, passando por necessidades. Relatou que o réu indicou onde estavam os entorpecentes, num local próximo à casa de seu pai, em um monte de areia. Afirmou que o acusado não é conhecido nos meios policiais. O réu confessou que estava traficando por necessidade, já que sua esposa estava grávida. Reiterou que o acusado, prontamente, indicou o local em que estavam as drogas. O depoente desenterrou o entorpecente e confirmou que a cor dos microtubos era igual àqueles apreendidos com o réu. Não reconheceu o acusado, uma vez que não era conhecido pelos policiais. Acredita que a distância entre o local onde o acusado foi abordado e onde estava o restante dos entorpecentes era de 50 metros, aproximadamente, em torno de um quarteirão.

Em seu interrogatório em juízo (fl. 208), o réu Kaio Felipe Custódio Gardinali confessou a prática do delito. Disse que na data dos fatos estava na casa de sua sogra almoçando e, por volta de 15h30min., foi até o bairro Rosele, onde pegou a droga em um "malote" de 30 (trinta) unidades. Relatou que já tinha vendido 05 (cinco) pinos e havia restado 25 (vinte e cinco) pinos com ele. Naquele momento, retirou três pinos do "malote" e conseguiu vender dois. Em seguida, se deparou com um veículo Sandero chumbo, onde estavam os policiais, os quais foram até o interrogando e sua namorada, abordando-o. Na abordagem, os policiais apreenderam os 03 (três) pinos que estavam com o interrogando, bem como R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, sendo que perguntaram para ele se tinha mais "B.O". O interrogando confessou aos policiais que do lado da casa de seu pai, havia mais 20 (vinte) pinos da droga. Disse que os policiais foram até o local e encontraram a droga, sendo que prontamente o conduziram até a Delegacia. Relatou que atualmente está preso por furto, porém, ainda não foi condenado.

Eis a prova oral colhida.

Encerrada a instrução processual, restou demonstrado que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e destinavam-se à comercialização ilícita, diante do que foi declarado pela testemunha comum em juízo, bem como pelas circunstâncias fáticas em que as drogas foram encontradas, somadas à confissão do réu em solo judicial.

O policial civil Ary Rideto Kaneyasu confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, afirmando que receberam uma denúncia da prática do tráfico de drogas no local dos fatos, sendo que foram até o local e avistaram o acusado entregando algo a uma pessoa não identificada, em um veículo. Durante a abordagem, foram localizados com o réu 03 (três) pinos de cocaína, sendo que o restante dos entorpecentes estavam enterrados em um monte de areia. Ainda de acordo com a testemunha, o réu confessou, prontamente, que estava traficando drogas no local, tendo indicado onde estavam armazenados o restante dos entorpecentes, os quais eram idênticos àqueles apreendidos na posse do réu.

Não há motivos para desmerecer a palavra do policial civil, uma vez que confirmada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 14, bem como pelos laudos periciais de fls. 33 e 104/106.

Registre-se que o relato prestado pelo agente público está em conformidade com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 08), o que lhe confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição que se presta a abalar, minimamente, a credibilidade da testemunha.

Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de

indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

Caracteriza-se, portanto, a prova produzida, como mais um elemento no conhecimento dos fatos pelo julgador, que deve apreciá-la em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Quanto ao acusado, observa-se que confessou a prática do delito em solo judicial, afirmando que foi até o bairro Rosele, onde pegou os entorpecentes em um "malote" de 30 (trinta) unidades. De acordo com o réu, ele já tinha vendido 07 (sete) pinos quando foi abordado pelos policiais civis, os quais apreenderam 03 (três) pinos em sua posse, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Ainda de acordo com o acusado, ele confessou aos agentes públicos que havia mais 20 (vinte) pinos da droga num local ali próximo, tendo os policiais encontrado o restante dos entorpecentes.

Vale destacar que o teor do que foi confessado pelo réu está em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A confissão do delito, de forma livre e espontânea, serve como importante elemento de convicção para demonstrar a autoria e amparar a condenação, quando encontrada sustentação nos demais elementos de convicção produzidos, como é o caso dos autos.

Ainda que o acusado pretendesse vender os entorpecentes em razão das dificuldades financeiras que estava passando, não há que se falar na causa excludente de ilicitude (estado de necessidade). Isto porque, não há prova de que a venda da droga serviria para assegurar a sua subsistência e de sua família, como última alternativa, a não ser na frágil e isolada escusa ofertada. Enfim, não restou comprovada qualquer ameaça a bem maior juridicamente tutelado a justificar e autorizar o cometimento do ilícito penal apurado nestes autos.

O modo como as drogas estavam acondicionadas e a quantidade apreendidas demonstram, de fato, que os entorpecentes se destinavam ao tráfico. Isto porque, foram apreendidas 23 (vinte e três) porções de pó branco, acondicionadas em microtubos do tipo eppendorfs, totalizando 28,44 gramas da substância entorpecente benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por cocaína, conforme laudos periciais de fls. 33 e 104/106.

Registre-se, ainda, que no mesmo contexto fático foram apreendidos R\$ 20,00 (vinte reais) na posse do acusado (fl. 101), não sendo comprovada nos autos a origem lícita do dinheiro, o que demonstra sua relação com o comércio nefasto da droga, notadamente pela confissão do próprio réu em solo judicial.

Com efeito, as condutas do réu, consistentes nas ações de "trazer consigo" e "ter em depósito" os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontram-se inseridas no rol descrito no "caput" do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, analisando os autos, é o caso de se aplicar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 em favor do acusado, uma vez que é primário (fls. 28/31), não ostenta maus antecedentes e não restou devidamente comprovado nos autos que ele se dedica às atividades criminosas e integra organização criminosa.

Em razão de todo o acima exposto, restou demonstrada e caracterizada a conduta do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

No tocante às circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e

artigo 59 do Código Penal, nada há que justifique a fixação da pena acima do patamar mínimo legal. Diante disso, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, uma vez que ausentes nos autos elementos que permitam aferir a capacidade financeira do acusado.

Incidem no caso as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (artigo 65, inciso I do Código Penal), uma vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fl. 15), bem como da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, por ter o réu confessado o delito em questão. Contudo, a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo legal, devendo permanecer inalterada em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é primário (fls. 28/31), não ostenta Maus antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e esteja envolvido com o crime organizado. A fração de diminuição deve considerar as circunstâncias do caso concreto. Tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida (28,44 gramas de "cocaína"), mostra-se razoável e suficiente a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços). Diminuo, portanto, a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa no valor de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo.

Conforme entendimento há muito exarado por este magistrado, o crime de tráfico fomenta inúmeros outros crimes e seria o caso de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, seja por conta de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, seja porque o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o artigo 44, "caput", da Lei nº 11.343/2006, é expresso ao proibir referido benefício, bem como não se consideraria apta para retribuição e prevenção da pena, a mencionada substituição no presente caso. Ressalto que o crime de tráfico de drogas gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Araçatuba-SP.

Contudo, em posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, foi determinada a fixação do regime aberto quando aplicado o redutor previsto no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), como se deu no caso em comento.

Nesse sentido, em observância à determinação da Corte Superior, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime aberto.

Por conseguinte, o réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, por preencher os requisitos do artigo 44, incisos I a III, e parágrafo 2º, do Código Penal. A prestação pecuniária consistirá no pagamento, em dinheiro, do valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, vigente na data do efetivo pagamento, que será revertido em benefício de entidade pública ou privada com destinação social, conforme artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, observando-se o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 46 e parágrafos do Código Penal) terá seu cumprimento disciplinado pelo Juízo da Execução, conforme as

aptidões do réu, e deverá se dar pelo período de 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Incabível no caso a concessão da suspensão condicional da pena, uma vez que foi deferida a substituição por pena restritiva de direitos, considerando, ainda, o montante da pena imposta (artigo 77, "caput", do Código Penal).

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para CONDENAR o réu KAIIO FELIPE CUSTÓDIO GARDINALI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", cumulado com o parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de multa no valor de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime aberto para o início do cumprimento. Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos moldes expostos na fundamentação desta sentença.

Defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, por estarem mantidas as circunstâncias que levaram a responder ao processo até aqui solto, considerando, ainda, o montante, regime e natureza da pena imposta.

DECLARO o perdimento da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) apreendida nos autos (fls. 14 e 101) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, uma vez que é produto do crime de tráfico praticado pelo sentenciado, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se que o réu é beneficiário da justiça gratuita (fl. 165).

P. R. e I.

Araçatuba, 3 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA